

1501833-25.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141675/2020 - 05º D.P. SANTOS, 11836842 - 05º D.P. SANTOS, 891/20/215 - 05º D.P. SANTOS, 2141675 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALCANTARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501833-25.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501833-25.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141675/2020 - 05º D.P. SANTOS, 11836842 - 05º D.P. SANTOS, 891/20/215 - 05º D.P. SANTOS, 2141675 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALCANTARA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

RAFAEL ALCANTARA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 10 de junho de 2020, às 16h25min, na Rua Haroldo de Camargo, nº 01, Bom Retiro, Santos, o denunciado trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que, policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo caminhar em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Antes de ser abordado, contudo, o denunciado dispensou 03 (três) porções de cocaína no chão.

Em revista pessoal, os policiais localizaram outras 03 (três) porções do entorpecente, totalizando 06 (seis) micro tubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo 1,8 gramas de cocaína.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 02/03). Auto de exibição e apreensão (fls. 06). Laudo do exame químico-toxicológico (fls. 100/102). O réu foi notificado (fls. 171), e apresentou defesa prévia (fls. 172/173).

A denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 178).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e foi decretada a revelia do acusado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal. Para tanto, argumentou que, embora esteja comprovada a materialidade delitiva pelos laudos periciais, não se conseguiu produzir em juízo prova apta a indicar o réu como sendo o autor do crime. Em juízo, os policiais afirmaram que não se recordavam dos fatos, mesmo após a leitura da denúncia. Assim, não há prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, apta a justificar a prolação de sentença condenatória.

A D. Defesa, em alegações finais, aduziu que a quantidade ínfima de drogas encontrada não pode lesar o bem jurídico tutelado, devendo a conduta ser classificada como atípica. Argumentou que é possível a aplicação do princípio da insignificância, sendo impossível a prolação de sentença condenatória. Alegou, ainda, que deve prevalecer a tese de descriminalização formal e despenalização do delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, por conta da norma penal não prever mais o caráter criminoso do fato. Diante do exposto, requereu a absolvição do acusado diante da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, não sendo o entendimento do juízo pela atipicidade, requereu que seja prolatada sentença de absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Embora comprovada a materialidade do crime descrito na denúncia, pelo laudo químico-toxicológico de fls.100/102, e pelo auto de prisão em flagrante, a autoria não restou satisfatoriamente comprovada.

A testemunha HEITOR ANTÔNIO DO VALE SILVA, policial militar, não se recordou sobre os fatos apurados nos autos.

A testemunha FELIPE CARREIRA VILELA, policial militar, não se recordou sobre os fatos apurados nos autos.

O réu RAFAEL ALCÂNTARA DE OLIVEIRA não foi interrogado, pois não compareceu ao ato. Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Primeiramente, anoto que não há que se falar em atipicidade da conduta de porte de drogas para uso próprio, permanecendo, sob a égide do princípio da legalidade, descrita como fato típico a conduta praticada pelo réu e expressa no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, já decidiu a jurisprudência no sentido de que não houve descriminalização da posse de entorpecente para uso próprio.

"HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. OBJETO JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Como é indubitado pela dicção legal, e vem sendo enfatizado nesta Corte Superior, o porte ou a posse de substância entorpecente para consumo próprio é conduta típica ainda que ínfima a quantidade apreendida. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Habeas corpus denegado." (HC n. 666.646/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.). "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR A ATUAÇÃO POLICIAL. AGENTE ABORDADO COM DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ATO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES DO ART. 48, §§ 2º E 3º DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - O artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que não preveja pena privativa de liberdade, permanece como crime. Não houve descriminalização da conduta, mas tão somente sua despenalização, vez que a norma especial conferiu tratamento penal mais brando aos usuários de drogas. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao "entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE

430.150/RJ, sedimentou orientação de que a Lei n. 11.343/2006 não descriminalizou a conduta que tipificou no art. 28, que, portanto, continua a configurar crime. Ocorreu mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção" (HC 406.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017)" (AgRg no HC n. 623.436/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/12/2021). V - Em casos dessa natureza, muito embora não se imponha a prisão em flagrante, é obrigação do policial conduzir o autor do fato diretamente ao juízo competente ou, na falta deste, à delegacia, lavrando-se, neste caso, o respectivo termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários, nos termos do artigo 48, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.343/2006. (...) Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.).

Em segundo lugar, com relação ao pleito defensivo de que seja aplicado o princípio da insignificância à conduta em análise, ressalto que este princípio não se aplica ao crime de porte de entorpecentes, haja vista que o consumo de drogas ilícitas é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, já que o bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública e não apenas do particular, mas, também, pelo perigo que este consumidor gera para a sociedade ao estimular o narcotráfico e, conseqüentemente, diversos outros crimes.

Além disso, é pressuposto do tipo penal que o acusado seja encontrado com pouca quantidade de droga, ou seja, apenas a suficiente para o seu uso, visto que, caso possuísse entorpecentes em quantidade maior e suficiente para poder oferecer a outras pessoas ou vender, o indivíduo poderia estar incurso no crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, e não no delito de porte de entorpecentes para uso. Nesse sentido: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. (...) 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido." (STJ - RHC: 37094 MG 2013/0118921-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)". Grifei.

Embora não seja possível reconhecer a atipicidade da conduta do acusado, no mérito, verifiquemos que tampouco é possível a prolação de sentença condenatória em desfavor de Rafael, uma vez que não ficou comprovada a autoria delitiva do crime de posse de entorpecentes para uso pessoal.

Ao final da persecução criminal, o conjunto probatório se ressentia de robustez quanto à autoria delitiva, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática do delito descrito na inicial por parte do réu.

Não obstante a existência do laudo do exame químico-toxicológico de fls. 100/102 que comprovou que os entorpecentes encontrados e apreendidos eram porções de cocaína, não foi possível se comprovar em juízo como os fatos se deram.

Em que pese a narrativa dos policiais militares na delegacia de polícia dizendo que detiveram o acusado na posse de entorpecentes, nenhuma das testemunhas se recordou dos fatos durante a audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para corroborar as provas colhidas no inquérito policial.

Saliento que é autorizado ao juízo que forme sua convicção com base nas provas colhidas na fase pré-processual, porém, elas têm que ser corroboradas durante a instrução criminal.

Portanto, as únicas provas testemunhas ameadas aos autos são oriundas da investigação e, não sendo elas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, não podem ser usadas como único e exclusivo meio de comprovar o fato apurado nos autos, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes para embasarem um decreto condenatório, pois não foram confirmadas na fase judicial Neste sentido:

“Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. (...) Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. (...) 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.” (HC 125035, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015). Grifei.

Sendo assim, não restou comprovado de forma segura que o acusado praticou o delito pelo qual foi denunciado.

O conjunto probatório torna-se, com isso, extremamente frágil e inconsistente, pois, em nenhum momento, restou seguramente demonstrada a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido, Nelson Hungria assinala que “a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”. (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

É cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, deve existir nos autos provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário, deverá incidir o princípio do in dubio pro reo.

No mais, o princípio supracitado não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que, diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Neste mesmo sentido, o esclarecimento de Carrara:

“No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza... não bastando a alta probabilidade..., sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio”. (in Prova Penal, Editora Aide, pág. 152).

As provas carregadas são extremamente frágeis, pois o conjunto probatório não foi suficiente para caracterizar a prática do delito de porte de porte de uso de entorpecentes para uso pessoal, sendo certo que é indevido embasar o decreto condenatório com os elementos acostados aos autos produzidos apenas e tão somente na fase de investigações.

Desta forma, a melhor solução é a absolvição por falta de provas, já que o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades e, sem a certeza total e plena da autoria e culpabilidade, não pode ser proferida a condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para ABSOLVER o réu RAFAEL ALCÂNTARA DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos na forma da lei.

P.I.C.

Santos, 30 de agosto de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA